按日连续处罚制度运行实效研究

李培培 *

内容提要：《环境保护法》规定的按日连续处罚制度实施至今已逾六年，对该制度研究的重点应从立法设计转向运行状况，从实效层面对按日连续处罚制度进行理论和实践探讨显得尤为必要。而运行实效的研究离不开对按日连续处罚制度运行中立法、执法和司法因素的综合系统考察，以实践考察为基础研讨按日连续处罚制度存在的立法、执法和司法问题，并提出按日连续处罚制度运行实效的提升应当加强配套制度衔接、重视执法程序规范、完善司法审查机制等建议。

关键词：环境保护　按日连续处罚　制度运行　法律实效

DOI：10.19350/j.cnki.fzsh.2021.03.011

一、按日连续处罚制度运行实效的廓清

（一）按日连续处罚制度运行实效的内涵

法律制度的运行实效是现有法律规范在执行、适用和遵守过程中表现出来的实现状态和社会效果，是法律上所架构的法律关系的权利义务主体对法律上权利义务的享有和实际履行。[①] 从宏观角度来看，以立法目的是否达到或多大程度上达到为标志；从微观角度来看，以法的规范性要求是否达到或多大程度上达到为评判尺度。法律运行实效主要归结为将法律的要求、愿望、目标变为现实，强调法律的实施状态，并从法的社会运行结果来考察法的社会调整功能。从主观价值评价角度分析按日连续处罚制度，主要是按日连续处罚制度所赋予行政机关的执法权能，以及其背后所隐藏的价值判断。从客观社会存在的角度看，按日连续处罚制度的运行实效指通过提高环境行政违法行为经济成本，形成惩罚与教育机制，通过经济刺激提高环境行政违法者的守法自觉性，形成环境执法领域的良性互动，亦指按日连续处罚制度对于各类主体自愿执行和遵守环境法律的推动力。这种推动力的产生以按日连续处罚制度在实际生活中被遵守、执行和适用为前提条件。《环境保护法》第五十九条[②] 的内容可以分为两个层次：前半部分是遵守法律的手段行为，后半部分是法律效果的结果，此两个部分相辅相成、缺一不可。同时，由于违法排污行为造成的环境危害的对象是公众，

* 中南财经政法大学法学院博士研究生。本文为研究阐释党的十九届四中全会精神国家社科基金重大项目“完善生态环境执法与司法衔接机制研究”（项目编号：20ZDA090）的阶段性研究成果。

① 李瑜青：《法律社会学教程》，华东理工大学出版社 2009 年版，第 29 页。

② 该条规定：“企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。”

具有典型的外部性，需要通过法律制度设计将这种外部性内部化。良好的社会秩序要以完善的法律制度建构为保障，首先就要在立法环节保障制度的合理性。[③] 其次，能否对违法排污行为进行有效的遏制，也是检验按日连续处罚制度法律实效的最主要标准。

（二）按日连续处罚制度运行实效的要素

目前学界关于法律实效的实现要素判定尚未形成统一观点，但基本上认同将行政执法的有效性、专业管理的高效性、守法的有效性和与社会经济发展的适应程度作为法律实效的重要考核指标。结合按日连续处罚的法律性质和基本特征，本文认为，按日连续处罚制度的运行实效应主要聚焦于如何保障按日连续处罚效用得以充分发挥。

首先，从法规范因素分析，按日连续处罚制度本身的合理性（立法）、法律在行政执法中得以规范执行（执法）、司法对法律的良好适用（司法）都是人们接受、遵守法律的原因，这三者均有助于按日连续处罚制度获得积极的运行实效。同时，三者之间也存在着天然联系和内在逻辑性，进行执法研究、司法研究的前提是准确理解立法理念、立法宗旨、立法原则；执法研究、司法研究的过程既在不断发现立法存在的不足或者缺陷，为立法研究提出问题，又可提出解决执法、司法问题的方案而为完善立法积累经验。由此，三者形成良性互动，进而为按日连续处罚制度运行实效的实现提供保障，扫清障碍。

其次，从法实践因素分析，按日连续处罚制度的社会实效，不能仅仅基于某一个独立事项，而应当多因素综合考虑。判断其社会实效的有无，不能简单地以违法案件数量的多少来判断：案件数量过多，并不意味着实效性良好，因为个体对该制度的普遍漠视是其效率低下的表现；案件数量过少，并不意味着实效性不佳，因为社会公众的普遍遵守是其价值最大化的体现。把违法行为控制在合理的范围，维护良好的社会秩序，才是法律实效的最佳体现。[④] 客观地判断按日连续处罚制度的法律实效，分析按日连续处罚能否对违法排污的后果进行有效的内部化，并通过内部化的程度分析环境权益在不同主体之间的分配和消耗，进而对社会秩序的状况予以分析，最终判断出法律运行实效的好坏。

综上，按日连续处罚制度运行实效的核心要素应归纳为如下三个：立法规范因素、行政执法因素和司法适用因素。

二、按日连续处罚制度运行实效存在的问题

违法企业为了获得利润，利用环境开发利用行为负外部性的特征，逃避污染环境的法律责任。由此，通过外部成本内部化，对违法排污行为实施按日连续处罚，不仅体现了损害担责原则，也有利于实现环境开发利用的公平性。[⑤] 但目前我国按日连续处罚制度的运行尚存在诸多问题。

（一）按日连续处罚制度运行的立法问题

《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》（以下简称《办法》）中将按日连续处罚简单地规定为行政处罚，而忽视了其具有的“执行罚”的外观，可能会在执法以及司法适用中产生法律上的

③ 陈明：《论法律实效评判的方法和标准》，载《辽宁行政学院学报》2007 年第 5 期。
④ 魏佳容：《转型期社会矛盾化解之道——以提高法律实效为视角》，载《理论月刊》2012 年第 4 期。
⑤ 邓可祝：《民法典视角下侵权法的环境规制功能研究》，载《法治社会》2020 年第 4 期。

理解偏差。[⑥] 同时，由于《办法》对行政自由裁量权的程序化控制不足，实际执法中可能出现“天价罚单”的情况，不利于环境执法社会实效的发挥。因此，保障该制度良好运行的立法规定尚需进一步完善。

1. 按日连续处罚立法协调性不足

生态环境行政主管部门出台了专门的部门规章，对按日连续处罚进行全面规定。前述《办法》即依据《环境保护法》和《行政处罚法》制定，要求按日连续处罚的执行要在两部法律规定的实体和程序规制范围内进行。《办法》更进一步揭示了按日连续处罚为行政处罚的法律性质，但此种法律定性，可能会引起法律适用上的规范冲突。在按日连续处罚制度设定之初，其与“一事不再罚”的关系便一直争论不休。通常，违法排放污染物的行为在现实中表现为持续性违法行为，例如长年累月的超标排污、治污设施设备闲置、偷排污水等违法行为，按照行政法理论，这种持续性违法行为，只要造成违法的状态一直持续，理应界定为一个“违法行为”，而且以一次行政违法对其进行处罚。在数量上人为地对其施加以“日”或者次数，将其分割为若干个不同的违法行为，这与我国的行政法基本理论不相适应，导致按日连续制度在立法体系上的协调性欠佳。

2. 按日连续处罚的可预测性不够

按日连续处罚制度执行中的不确定因素多，可预测性不够。《环境保护法》第五十九条是定性规定，对于行政相对人行为的描述是“排放污染物”，对行政相对人改正行为的表述是“拒不改正”或“不按要求改正”，行政机关在适用过程中有较大解释余地。而《办法》的操作性规定可能存在约束力的不足，从而导致实体上和程序上行政机关的裁量权过大。以行政相对人的改正行为为例，有完全改正、存在改正行为但没有达到规定标准和完全没有改正等多种情形，在完全不改正与彻底改正之间存在中间形态，现有法律对于中间形态的规定过于笼统，行政机关的裁量空间大。此外，对于限期改正，在不同条件下因情形特殊可能造成客观上的履行不能，也可能因不可预见因素对行政相对人造成重大损失，这些都导致可预测性的降低。

3. 按日连续处罚的效果评估机制欠缺

按日连续处罚是为了延伸对违法排污行为的计量范围从而扩大对排污行为所造成的外部性的统计范围，尽可能地使罚款接近排污所造成的外部成本，从而在经济上对排污行为形成强大的压力，迫使排污者在合法排污限度内自觉守法。环境行政主管部门可以开出巨额的罚单，但是最终责任如何落实，需要对“按日连续实施”效果进行评估。行政相对人造成的环境负面影响，通过罚款形式进行处罚，虽然在程序上对行政机关是便利的，但其社会实效值得商榷。目前按日连续处罚制度的内生问题是如何合理判定罚款数额，也就是说罚款在什么范围内可以充分发挥经济制裁作用。按日连续处罚制度的合理性在于通过按日连续处罚将外部性成本内部化，使得各方主体的利益得以平衡。当处罚的数额超过污染者所造成的外部成本时，处罚过重，在影响经济发展的同时，也可能对污染者存在反面的诱导；如果处罚的数额低于污染者的外部成本，处罚过轻，对污染者实际上是变相的鼓励。因为立法缺乏有效的效果评估机制，可能会导致按日连续处罚制度滥用。因此，应尝试加入经济学分析，合理判定启动条件和罚款标准，不断夯实按日连续处罚的合理性基础。

（二）按日连续处罚制度运行的执法问题

环境保护主管部门执法水平与执法能力的高低，直接影响着按日连续处罚法律实效的实现程

⑥《办法》第一条规定：“为规范实施按日连续处罚，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律，制定本办法。”

度。这里谈到的“执法”为狭义的“执法”，即不包括国家司法机关及其公职人员按照法律规定的职权和法定的程序实施法律的活动，而仅指行政管理过程中的贯彻实施法律的活动。⑦

1. 按日连续处罚执法时效性较差

根据按日连续处罚的实施程序要求，《环境保护法》对行政机关实施按日连续处罚提出了相当严苛的条件：必须以污染者曾经接受过行政处罚（罚款）为适用基础，这种制度设计在很大程度上制造了执法的困境。因为污染者可以通过行政复议或者提起行政诉讼的方式拖延时间，那么完整的行政处罚周期就被延长了。尽管《行政处罚法》确立了“不停止执行”的基本原则，但是按日连续处罚一般采取申请法院执行的方式，在实践中造成裁判和执行的分离，这势必会影响按日连续处罚的适用效果。另外，由于司法机关和行政机关之间“部门墙”的存在，司法机关在审判任务繁重的情况下，无力分出更多的人力、物力、财力等资源投入到这类申请强制执行的案件中，从行政机关申请强制执行到司法机关实际强制执行之间存在较大的“时间差”，污染者在“时间差”内持续排污，按日连续处罚的实效将难以发挥。

2. 按日连续处罚执法程序缺损

关于是否启动按日连续处罚的问题，行政执法机关具有较大的裁量权，如此一来，可能会导致裁量的不合理。但行政执法应具备合法性要件而且要尽量做到合乎情理，保障违法排污者的合法权益，避免公权力对私权利的过度干预。这就要求在作出按日连续处罚决定时，应当充分考虑其他可替代性的行政手段，慎用这一严厉的惩戒手段，由此设立“合理审查”程序就显得尤为必要。环境保护主管机关为了实现具体执法目的，可以运用法律所赋予的多种行政手段，按日连续处罚只是其中之一，是否运用按日连续处罚应当视执法的具体情况而定。如果按日连续处罚的运用无法真正实现提高违法成本或减少违法收益的作用，甚至在一定情况下“变相鼓励”环境违法行为，那么在这种情况下就应当采取其他环境执法行为，避免出现作出处罚决定却不能执行进而导致违法行为继续的现象，这是对排污者私人利益和社会公共利益的双重损害。

（三）按日连续处罚制度运行的司法问题

法律的实效性就意味着法律必须成为具体的社会争议以及社会问题解决的标准，而这首先就要求对一般性的法律进行具体解释以对应社会事实，否则法律就逐渐失去其在具体社会事实中的权威，进而沦为一纸空文。由此可见，司法作为法律运行的重要环节对于法律实效的实现具有重要意义。

1. 按日连续处罚司法审理困难

现行法律体系中，行政复议和司法审查是对按日连续处罚法制化矫正、救济的重要手段。其中，排污者不服行政执法机关按日连续处罚决定的，可依据《行政复议法》《行政诉讼法》等法律申请行政复议或者行政诉讼。但是按日连续处罚的法律性质争议以及处罚形式的特殊性，使按日连续处罚进入司法程序后的审理和裁判仍存在一定争议，从而带来法律适用的问题。尽管有《行政诉讼法》及其相关配套规定可以为按日连续处罚进入司法程序提供基本框架，但按日连续处罚自身所固有的特殊性，主要体现在实施阶段的程序性要求，这些都需要司法中通过解释说理来完成，增加了司法审判难度。

2. 按日连续处罚司法矫正不足

《行政诉讼法》规定对行政行为的审查主要以合法性为重点，对于行政行为的合理性审查缺乏

⑦ 雷喻义、许之景等：《行政机关执法问题研究》，载《中国法学》1988 年第 4 期。

硬性约束，这在按日连续处罚中体现得更为明显。[⑧] 这主要是由于对环境违法行为的行政罚款主要采用定额模式，而按日连续处罚通常是对定额的连续加倍。但是，定额处罚本身存在对违法行为具体特征考虑不周的问题，而按日连续加倍又更加凸显了这一弊端。因此，对按日连续处罚行政纠纷案件的审理，应当在合法性要件审查的同时，重视通过司法审判的方式对不当的按日连续处罚决定进行矫正。以云南蒙自银烁矿冶有限公司（以下简称银烁公司）诉红河哈尼族彝族自治州环境保护局（以下简称环保局）行政处罚纠纷一案为例，[⑨] 虽然最终法院撤销了被告连罚的决定，但环保局在银烁公司二氧化硫超标 12.27 倍时适用“顶格”的 100 万元罚款[⑩] 是否适当，以及超标 1.6 倍是否仍属于“严重超标”，这些涉及案件实质合理的因素，在判决中却并未涉及。[⑪] 而且，就银烁公司已经采取措施积极整改，环保局后续复查时发现其超标排污的情况已经大大减轻的情形，法院审理时也未纳入考量，仍旧按照“原处罚数额”进行按日计罚，恐存在僵化适用法条之嫌。

通过司法审查的方式，对按日连续处罚制度下的行政裁量权进行事后干预，是避免或减少按日连续处罚行政裁量权滥用、从而造成按日连续处罚制度异化的重要手段和保障。[⑫] 但是，基于我国行政职能部门的自由裁量权的权限较大的现状，涉及按日连续处罚的案件即使进入行政诉讼程序，仍然受到多方力量的影响和制约，这势必会影响按日连续处罚制度在司法适用中的实效性发挥。

三、按日连续处罚制度运行实效欠缺的原因

（一）配套制度衔接不够

从立法上讲，按日连续处罚制度尚需与其他环境法律制度不断磨合，相互协调。从执法上讲，按日连续处罚的实施需要生态环境主管部门严格执法，也应加强与其他相关职能部门的协作，这样才能有效控制环境行政违法行为，减缓环境恶化趋势，改善环境状况，实现生态法治。

1. 按日连续处罚与行政拘留衔接不畅

行政拘留是对公民人身自由的限制，是比罚款更加严厉的行政处罚种类。现行按日连续处罚制度的设计方式，与既有的“移送难”固疾结合起来，造成按日连续处罚与行政拘留不协调的现象。实践中生态环境主管部门对符合公安机关拘留情形的环境案件的移送并不积极，除部分环保执法人员的认识问题，主要原因有两个方面：第一，在现行财政体制下，行政罚没收入划归地方财政收入中，而地方财政会按照一定比例向罚没机关返还。罚款的处罚功能也可能随之变异，行政罚款能给生态环境主管部门带来经济效益，因此，生态环境主管部门有可能更倾向使用罚款这一行政处罚手段。第二，移送案件是行政绩效与责任风险共存的行为。适用按日连续处罚的案件多为屡罚不改的违法行为，除向移送公安机关处理时组织证据、配合调查等行政成本更高之外，往往还可能有生态环境主管部门滥用职权、渎职等原因裹挟其中。移送公安机关在有的情形下也是生态环境主管部门

⑧ 刘学涛：《按日连续处罚案法定程序适用研究——以银烁公司诉红河州环保局环境保护行政管理案为例》，载《法律适用》2019 年第 10 期。

⑨ “蒙自银烁矿冶有限公司诉红河哈尼族彝族自治州原环境保护局行政处罚纠纷案”，云南省蒙自县人民法院（2017）云 2503 行初 30 号行政判决书。

⑩《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条规定：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：……（二）超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的；……”

⑪ 严厚福：《“比例原则”下我国环境执法按日连续处罚制度的完善》，载《中国环境管理》2021 年第 1 期。

⑫ 杨建顺：《行政规制与权利保障》，中国人民大学出版社 2007 年版，第 516 页。

自曝软肋的过程，自行罚款处理可以避免配合公安机关的程序负担和行政风险。[13] 尽管行政执法中罚款成为最常用手段，但单纯罚款对排污者持续性违法行为的威慑力是不足的，因此，如果制度衔接不畅，其法律实效势必大打折扣。

2. 按日连续处罚与刑罚衔接不畅

当环境行政违法行为符合刑法上环境犯罪的构成要件时，应当追究刑事责任，而不能以行政处罚代替。由于环境违法行为对于生态环境的破坏有不可逆转的特点，环境法律规范的有效性不在于其处罚的频率，而在于其环境污染预防功能，因此刑罚威慑是非常有必要的。然而，虽然《刑法》规定了环境犯罪，其后的修正案、司法解释也不断完善其罪名和构成要件，但是在执法实践中行政机关处理的多，对严重的环境违法行为真正移送司法机关却很少，这样的背景下出台按日连续处罚制度，既可能会陷入固有执法、司法不衔接困境，还可能形成新的衔接不畅问题。

（二）执法程序规范化不足

程序合法是行政执法活动的内在要义，程序是具有“独立于结果之外而又内含于本身内在品质”的正义标尺。[14] 具体而言，就是要保障在行政执法活动中各个阶段都是按照法定的要求，符合法定的实施条件，终极目的是保障相对人合法权益和提高行政执法的效率。实践中，有的按日连续处罚是为了罚款而罚款，但罚款本身并不是按日连续处罚制度目的，只是推动违法排污主体履行环境保护义务的手段而已。不重视程序规范性，激进地推进按日连续处罚制度极容易造成公权力对私权利的侵犯。

从权力结构上讲，行政机关做出行政处罚实际上是公权力行使的过程，在对排污企业等权利主体进行监管过程中应当坚持权力行使的合法性，这种合法性在程序规制中主要体现为对公权力行使过程的管制以及对权利主体合法权益的保护，包括限制执法主体、明确权力界限，以及建立权利救济机制。按日连续处罚不但需要以程序规制加强对公权力的限制，也要为环境利益和经济利益在执法过程的博弈提供有效制衡。基于这种功能，除加强环境信息公开、进行听证、提出异议等特定程序外，还应在个体权益保护优先理念指导下，平衡按日连续处罚所涉各方利益，推动执法程序规范化。

（三）司法监督力度欠缺

按日连续处罚作为惩处环境行政违法行为的重要手段，其本质属于公权力对私权利的规制，而公权力存在恣意性，如果不对公权力加以限制和监督，环境法按日连续处罚制度便很有可能损害环境污染企业的合法利益。如果欠缺对做出按日连续处罚的行政机关的内部监督，同时也缺乏司法监督，容易引起公权力寻租的状况，在对环境污染企业进行严格治理时缺乏透明度和公开性，亦可能导致政府自由裁量权的滥用。可见，离开有效的监督机制，将造成按日连续处罚法律制度的实效性严重下降。

从内部约束机制来看，上一级生态环境主管部门是否应当加强对下一级的监管？比如，按日连续处罚如果涉及金额巨大，针对“重大的环境违法行为”，是否应当向上一级的生态环境主管部门进行备案？如果上级机关不能及时有效监督下级的行政执法活动，不合理的行政处罚决定就难以通过内部机制予以及时纠正。

此外，司法监督作为重要监督手段，对具体行政行为的监督职能主要体现在：一是违法排污者

⑬ 彭新喜：《我国环保按日计罚制度功能的反思与完善》，载《中南林业科技大学学报（社会科学版）》2016 年第 2 期。

⑭ 周佑勇：《行政法的正当程序原则》，载《中国社会科学》2004 年第 4 期。

对按日连续处罚的决定不服时可以提起诉讼，寻求权利救济，保障自身的合法权益；二是按日连续处罚由于罚款数额大，其执行需要司法机关的协助，在行政机关申请法院非诉执行时，应当对行政处罚的合法性提交证明材料，司法机关对其存有疑问的可以要求行政机关作出说明，证据链条不完整的，可以驳回行政机关的强制执行申请。目前，这两方面的监督皆存在不足。

四、按日连续处罚制度运行实效的保障机制

实现按日连续处罚的法律实效关键在于法律规范的完善程度、执法部门的实施情况和处罚数额上不封顶的威慑效果等因素。实践中按日连续处罚制度虽然对环境违法行为产生了一定的震慑，但也存在局限性。比如，在处罚金额达到一定数值后，相关行为人往往会选择停产甚至破产来规避“天价”罚单，这固然表明了按日连续处罚制度的约束力，但是，一旦罚款数额超出一定水平之后，其威慑力反而无从发挥作用。按日连续处罚制度要达到的法律效果是环境违法者能够感觉到“痛”，并改正其违法行为，而不是希望环境违法者“僵”或“死”，对社会经济产生消极、负面的影响。因此，从此角度而言，按日连续处罚制度的运行需要限定在合理限度内，并且需要相对完善的保障机制促进其法律实效的实现。

（一）加强配套制度衔接

在当前社会经济快速发展的潮流下，法律作为人类社会行为规范越来越显示出共同协作的局面，即任何一项法律制度或规则的实施总是需要其他法律制度或规则的支持，法律作为一个整体，往往牵一发而动全身。尤其是在当前环境日益恶化，环境执法面临种种困难的情况下，制度衔接和配合就显得尤为重要，因此，必须在环境法律责任分配的大格局下看待按日连续处罚制度，即该制度的顺利实施需要其他配套制度，如“诚信罚”制度、“查封、扣押”“限产、停产”“移送拘留”等制度的支持和配合，而如何选择和组合需要根据环境违法案件的具体情形做出相应的判断。受篇幅所限，在此仅讨论按日连续处罚与“诚信罚”和“查封、扣押”的衔接。

1. 按日连续处罚与“诚信罚”的衔接

“诚信罚”制度[15]规定在《环境保护法》的第五十四条第三款，其基本内涵是环境执法机构应当对环境违法者的违法信息建立社会诚信档案，并及时向社会进行公布。[16]“诚信罚”最大的作用或功效在于通过信息公开，解决执法者信息不对称问题，这里的不对称不仅仅指的是执法者与违法者之间信息不对称，更包括各行政部门之间信息不对称。这是由于在我国的行政管理体系下，政府机构或公共事业单位掌握了大量的社会信息，但各部门之间因为管理领域、执法方式、执法依据、行政级别等诸多因素的影响，信息无法充分共享，从这一角度而言，“诚信罚”的出现一定程度上解决了各部门之间的综合执法问题，有利于实现信息共享共用，共同执法。

按日连续处罚制度与“诚信罚”制度的衔接，关键在于两个方面：首先是作为行政处罚手段的

⑮ 事实上，环保领域的诚信体系建设早已起步，但历程却并不顺利。早在 2002 年，《清洁生产促进法》就规定建立环境保护“黑名单”制度。2007 年 7 月，国家环保总局、人民银行、银监会联合发布《关于落实环保政策法规 防范信贷风险的意见》，指出要加强环保和信贷管理工作的协调配合，强化环境监督管理，严格信贷环保要求。经过环保部门与人民银行的共同努力，有近 4 万条环保信息被纳入人民银行征信管理系统，许多环境违法企业因此被银行限制或收回贷款。虽然环保执法部门与其他职能部门之间已经形成了一些信息共享和执法衔接渠道，但从范围和规模来看还远远不够。参见刘晓星、邢飞龙等：《公开环保黑名单》，载《中国环境报》2014 年 3 月 20 日第 10 版。

⑯《关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56 号）要求：“建立环境信用评价制度，将环境违法企业列入“黑名单”并向社会公开，将其环境违法行为纳入社会信用体系，让失信企业一次违法、处处受限。”

组合，在处罚程度上，一般而言，前者要重于后者，因此在面对具体案件时，可以考虑首先适用“诚信罚”，以达到警示和教育的作用，督促违法者停止环境违法行为。其次是二者在执法技术或手段上的衔接，例如，环境执法部门在决定对违法者实施按日连续处罚时，通过“诚信罚”制度建立的诚信档案体系，可以及时获得该违法者的诚信信息，从而对后续的环境执法发挥作用。再者，“诚信罚”所建立的诚信档案体系也可以及时更新违法者接受按日连续处罚的信息，这样，既能够有效警示和教育相关违法者，也可以防止中小企业通过更换企业注册信息、恶意分立、合并等方式“改头换面”，在事实上起到阻止违法者继续实施违法排污行为的效果。另外，可以考虑在“诚信罚”制度中引入信用分级制度，[17] 信用分级制度能够更好地区分不同行为主体在生态环境部门执法过程中的表现，生态环境部门可以针对不同信用等级的行为主体采取不同的执法策略和执法手段，就按日连续处罚制度而言，也可以在信用分级制度中明确可能适用的对象，环境执法部门甚至可以针对信用较差行为人提高执法检查的频率，这对于提高按日连续处罚制度法律效率具有实际操作价值。

2. 按日连续处罚与“查封、扣押”的衔接

我国《环境保护法》第二十五条规定了“查封、扣押”措施。环境行政执法的“查封、扣押”与司法领域的“查封、扣押”的内涵和内容不同，主要区别在于，环境行政执法领域的“查封、扣押”仅涉及“造成污染物排放的设施、设备”，对于违法者的其他财产如银行存款、厂房、车辆、其他生产生活设备等均无权查封、扣押。而司法领域上的“查封、扣押”，其适用范围相对宽泛得多。另外，环境行政执法领域的“查封、扣押”，仅作为一种保障性的行为发挥作用，无权对查封、扣押物进行处分，而司法意义上的“查封、扣押”则可能涉及物品的处分，例如没收、拍卖、变卖查封扣押物等。同时，相较于司法领域“查封、扣押”的执行强制性，生态环境主管部门的查封扣押缺乏强制性保证。

具体到按日连续处罚和查封扣押的衔接，可以考虑对按日连续处罚制度设计进行适当调整。例如，在确定适用按日连续处罚制度时，生态环境部门应当明确事后检查的具体期限，而不是拖延事后的检查，放任罚款数额的增加。同时，对“查封、扣押”制度本身，也应当做出适用情形的具体规定，例如相关领域的法律法规可以采用列举方式对应当采取和可以采取查封、扣押措施的典型情形做出规定，甚至考虑将查封、扣押措施作为某种情形下适用按日连续处罚的前置程序或保障措施。

（二）明确环境行政执法限度

1. 防止自由裁量权滥用

适度自由裁量权在环境行政执法活动中是必不可缺的，规范环境行政执法环节的程序也就是保障行政自由裁量权在合理限度内得以实施。自由裁量权的运用体现在生态环境主管部门对环境行政违法行为实施惩戒时执法手段的选择，即何时启动按日连续处罚，如何下达按日连续处罚决定，确定处罚幅度大小等方面。对于自由裁量的规制，一方面要求在法律规定条件下采取行动，也就是说，自由裁量应当是根据具体明确的法律规范做出的，合乎法律构成要件，另一方面要求在执法中尽量排除执法者个人主观因素，只有这样，自由裁量权的行使才能够控制在有效限度内，保障其发挥最大的功效。按日连续处罚制度的适用，违法行为认定是重要的一环。由于计罚考量因素不多等多种原因，我国的按日连续处罚制度存在广泛的自由裁量空间，如果不依法控制，执法的公正性将

[17]《关于加强企业环境信用体系建设的指导意见》（环发〔2015〕161 号）以及《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150 号）对于企业环境信用评价制度做了规定。

难以保证。[18] 对于违法行为的判定要求执法者充分考虑违法行为各个要件，综合考量计罚因素，从违法行为后果严重性、违法者的主观过错等方面进行全方面衡量，确保执法行为公正性。

2. 明确环境执法原则

环境执法是一个系统工程，明确执法原则为按日连续处罚的执法树立“标杆”。在实施按日连续处罚时，应明确需要保护的环境利益与其他社会、经济等因素之间的优先顺序。需要强调的是，按日连续处罚的目的在于遏制环境行政违法行为，而不是一味地增加处罚数额。因此，建议明确以下原则：

首先，理顺价值位阶，平衡公私利益。[19] 按日连续处罚是对违法者施加的经济处罚，其直接目的就是通过加重的惩罚对违法者形成一种威慑和压迫，迫使其停止违法行为。但是环境公益与个人财产权益的关系需要明确界定，具体到环境行政执法裁量中，就是要注重对私权利的保护，保障制度实施公平公正。

其次，避免执法手段单一化。按日连续处罚只能解决特定的问题，本身也存在一定局限性，作为众多执法手段的一种，生态环境主管部门在行政执法过程中应当避免执法工具选择的偏差，摆脱对“好用”或者“创收”执法手段的路径依赖。生态环境主管部门在做出按日连续处罚决定时不仅要慎重，而且在发现按日连续处罚不能处理的情况时，应马上转变方式，选用其他行政手段，及时遏制污染的严重化，避免对生态环境造成更加严重的损害。

最后，形成公私利益良性互动。在实施按日连续处罚的过程中，公私利益博弈存在于每个执法阶段。如果违法排污者可以积极配合生态环境主管部门执法，如呈报改善进度、报请查验等，不仅可以降低企业遭受生态环境主管部门复查时实施按日连续处罚的风险，也可以节约企业环境保护成本。这不但对于违法排污者意义重大，而且对生态环境主管部门而言，及时的信息沟通、合作履行环保义务都是提高行政执法效率的重要手段。当然，良性互动不仅体现在行政主体和相对人之间，广泛的第三方参与亦是提升违法排污者守法程度的重要路径，比如代履行制度在面临紧急情形时就有比按日连续处罚更大的优势。此外，主动公开执法活动、接受监督，也是公私协作的重要方式。[20]

（三）完善司法审查机制

司法审查在现代民主社会中处于重要的地位，司法审查通过司法活动对国家机关滥用国家权力、玩忽职守以及行政不作为的行为进行纠正，对由此造成的相关公民或法人合法权益的损害进行弥补。司法审查具有中立性和终局性的特征，在法律体系中发挥矫正和救济的作用。现实中，司法作用的发挥主要是通过个案的解决来实现的，在个案的解决过程中，司法也实现了法律实效。

对于按日连续处罚制度来说，完善司法审查机制具有重要的意义。按日连续处罚通过对个案中相对人违法行为实施按日计罚，罚款数额具有上不封顶的特点，因此，需要赋予司法行政相对人救济的权利。具体而言，行政诉讼可以更好地界定相关案件的事实，对环境执法部门实施按日连续处罚的合法性、合理性等进行全面判断。实践中，完善司法审查机制需要诉讼程序根据按日连续处罚的特点进行调整，例如，在生态环境主管部门决定对相对人采取按日连续处罚措施并告知相对人

⑱ 胡红玲：《环境保护按日计罚制度适用反思与完善——以美国环境保护按日连续处罚制度为借鉴》，载《政治与法律》2018年第8期。

⑲ 秦鹏：《环境公民身份：形成逻辑、理论意蕴与法治价值》，载《法学评论》2012年第3期。

⑳ 事实上，信息披露不仅要求排污者公开涉及环境执法的相关信息，以便于环保机关和公众对其进行监控，也要求政府公开做出按日连续处罚所依据的证据信息，以此作为法院审查或公民评价环保机关行政裁量权合理性的基础。从这个角度看，信息披露也是公私协作的一种表现形式。

后，相对人向法院提起诉讼，此时处罚并未开始计算，在诉讼程序中，该制度是否应当中止执行？本文认为，从按日连续处罚制度的内容来讲，该制度是一种可预期的不利后果，相对人在提起诉讼时对这种处罚在一定程度上是可预见的，且诉讼本身不能成为计罚中断的法定条件，因此，在这情况下，按日连续处罚应当继续计算，最后根据司法审查的结果进行执行。

结语

按日连续处罚法律实效的立法因素、执法因素和司法因素不能简单割裂地看待，三者之间具有天然联系，也存在内在逻辑性。进行执法研究、司法研究的前提是准确理解立法理念及合理适用立法规定，同时，在执法、司法过程中不断发现立法存在的不足或缺陷，亦为立法的不断修正积累经验和提出解决方案。按日连续处罚制度的完善需要多举措并用，遵守制度运行中的执法程序，完善司法监督，确保制度落到实处，以实现良好的法律实效。

Abstract: It has been more than six years since the implementation of the system of continuous penalty on a daily basis, which is stipulated in the Environmental Protection Law, and the focus of research on the system should shift from the legislative design of the system to the operation of the system. Therefore, it is particularly necessary to explore the theory and practice of the system at the level of legal effectiveness. The effectiveness of the law cannot be achieved without a comprehensive and systematic examination of the legislative, enforcement and judicial factors in the operation of the system. This paper examines in detail the legislative, enforcement and judicial problems of the system, and then proposes that the legal effectiveness of the system should be achieved by strengthening the convergence of supporting systems, paying attention to the regulation of procedures and improving the judicial review mechanism.

Key Words: Environmental Protection；Continuous Penalty on a Daily Basis；Operation of the System；Legal Effectiveness

（责任编辑：刘长兴）